

0000283-71.2022.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Simone Rodrigues Valle

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... ao crime de associação para o tráfico e condenação pelo prática do crime de tráfico de drogas. Manifestou-se sobre a dosimetria da pena (fls. 287/288).

A Defesa, por sua vez, requereu, preliminarmente, a nulidade do feito, considerando que a apreensão do entorpecente se deu a partir de revista pessoal realizada por guardas civis municipais. No mérito, requereu a absolvição ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

1ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12902-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000283-71.2022.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000283-71.2022.8.26.0545

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 8155-1/2022 - Delegacia Seccional

Bragança Paulista, 54/2022 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes

Bragança Paulista

Autor:

Justiça Pública

Denunciado e Réu:

Francisco Alves e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Simone Rodrigues Valle

Vistos.

FRANCISCO ALVES e CAIO DUARTE, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Consta da denúncia que, em data e local incerto, mas no ano de 2022, nesta cidade e Comarca de Bragança Paulista, os acusados associaram-se, entre si, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Consta, ainda, que no dia 06 de maio de 2022, por volta das 17h50min, na "Concha Acústica", localizada na Avenida São Lourenço, 5333, bairro São Lourenço, nesta cidade e Comarca de Bragança Paulista, os acusados, agindo em concurso e com unidade de desígnios, traziam consigo para entrega a consumo de terceiros, 1 (uma) porção de maconha pesando, no total, aproximadamente 2,0g (dois gramas), 31 papalotes de cocaína, pesando no total, aproximadamente 35g (trinta e cinco gramas)

e 94 (noventa e quatro) pedras de crack, pesando, no total, aproximadamente 31g, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 681,00 (seiscentos e oitenta e um reais) em espécie.

Os acusados foram devidamente notificados (fls. 122/123 e fls. 276/277) e apresentaram resposta à acusação às fls. 232/233.

Após, a denúncia foi recebida para o acusado Caio Duarte, em 15 de julho de 2022, às fls. 235/237.

Durante a audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes e, ao final, os réus foram interrogados (fls. 287/288).

Encerrada a instrução, as partes se manifestaram em debates orais, oportunidade em que o Ministério Público requereu a parcial procedência da ação, com a absolvição dos acusados quanto ao crime de associação para o tráfico e condenação pelo prática do crime de tráfico de drogas. Manifestou-se sobre a dosimetria da pena (fls. 287/288).

A Defesa, por sua vez, requereu, preliminarmente, a nulidade do feito, considerando que a apreensão do entorpecente se deu a partir de revista pessoal realizada por guardas civis municipais. No mérito, requereu a absolvição dos acusados com relação ao artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06 e a absolvição do réu Francisco com relação ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado e o cumprimento da pena em regime aberto com a consequente substituição da pena corporal pela restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Inicialmente, compulsando melhor os autos, verifico que a denúncia foi recebida somente para o acusado Caio, motivo pelo qual, nesta data, recebo a denúncia oferecida também contra o acusado Francisco Alves como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal. ANOTE-SE.

A defesa alega a nulidade da prova produzida nos autos, uma vez que a apreensão da substância entorpecente se deu a partir de revista pessoal realizada por guardas civis municipais, alegando que os referidos servidores públicos não possuem legitimidade para exercício de tal função.

O artigo 144, § 8º, da CF/88 preceitua que:

"A segurança pública, dever do Estado, direto e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: § 8º - Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei."

Logo se verifica que a Constituição Federal não retira dos membros da Guarda Civil Municipal a condição de agentes de autoridade, legitimados a praticar atos de defesa à sociedade, inclusive em situações análogas às da espécie, qual seja, prender/apreender em flagrante e acompanhar a mercancia de drogas.

Ademais, o Estatuto dos Guardas Municipais (Lei nº 13.022/14) trata da possibilidade de patrulhamento preventivo (artigo 3º, III) e da colaboração integrada com os demais órgãos de segurança pública (artigo 5º, IV).

Portanto, é conferido aos Guardas o poder de polícia, o que legitima tal atuação. Neste sentido é o entendimento do C. STJ:

"Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ." (STJ HC 290.371/SP Rel. min. Moura Ribeiro Quinta Turma j. 27.05.14)

Assim, afasto a preliminar alegada, pois a atuação da guarda não foi ilegal.

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito de tráfico encontra-se totalmente demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 11/13, auto de exibição e apreensão às fls. 08/09, pelo laudo de constatação preliminar (fls. 10) e, em especial, pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 97/105), que apontou resultado positivo para tetrahidrocannabinol e cocaína nas substâncias entorpecentes apreendidas na ocasião, pelo laudo pericial de fls. 130/188, bem como pela prova oral produzida nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria também restou comprovada.

Na fase policial, o acusado Francisco disse que estava sozinho na via pública, ocasião em que foi abordado pelos guardas. Havia outros indivíduos no local, que fugiram. Confirmou que havia somente uma pequena porção de maconha esfarelada em sua posse para seu próprio uso e certa quantia em dinheiro, não se recordando da quantia exata. Afirmou que possui trabalho lícito e recebe R\$ 2.030,00. Negou a traficância e disse não conhecer o acusado Caio.

Em juízo, o réu disse que somente foi encontrada uma porção de maconha na sua mochila para seu consumo e que desconhece a cocaína encontrada. Confirmou que a quantia em dinheiro era sua, que conhecia o corréu Caio de vista e que, na ocasião, apenas se cumprimentaram, momento em que a guarda chegou. Confirmou que seu apelido é Tico.

O acusado Caio, na fase policial, negou os fatos dizendo que, na ocasião, encontrava-se na rua e que havia ido ao local para comprar uma porção de maconha. Em dado momento, encontrou um rapaz desconhecido, que lhe pediu para que segurasse algumas porções de drogas apenas por alguns instantes até que ele retornasse e, nessa oportunidade, apareceram os guardas municipais e o abordaram. Afirmou que o dono da droga fugiu do local e que os guardas encontraram as drogas e R\$ 130,00 em dinheiro, fruto de seu trabalho. Negou a traficância e disse que não conhece o corréu.

Em juízo, confirmou que foi pago para fazer o transporte da droga para um sítio, que não conhece o corréu e não conversou com ele.

O guarda municipal Marcos Kendi Koguti disse que, na data dos fatos, estava juntamente com seu parceiro em moto patrulhamento próximo ao escadão, em frente à concha acústica, local já conhecido como ponto de tráfico e, ao passar por trás do escadão, depararam-se com os acusados, que, ao notar a presença da guarda, correram, sendo abordados metros à frente. Com o réu Caio foram encontradas 94 pedras de crack no bolso de sua blusa e a quantia de R\$ 136,00 em notas trocadas. Indagado, o acusado não soube informar sobre a procedência do valor em dinheiro e, com relação ao entorpecente, disse que estava levando à festa do peão no posto de Monta. Com o acusado Francisco, foi encontrada uma porção de maconha e 31 papелotes de cocaína guardados dentro de sua roupa, na cintura, além da quantia de R\$ 545,00 em notas trocadas. Indagado, o réu permaneceu calado. Diante disso, os acusados foram conduzidos à Delegacia. Afirmou que os dois foram vistos juntos no escadão e que fugiram juntos, para o mesmo caminho. O réu Caio disse que os dois estavam sentados no local, mas não disse se se conheciam, enquanto o réu Francisco permaneceu todo tempo em silêncio.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Gustavo Henrique Ibraim, guarda municipal, que acrescentou que abordou o réu Caio enquanto seu parceiro abordou o réu Francisco. Disse que com o réu Caio as drogas e o dinheiro foram localizados no bolso de sua calça e que as drogas e dinheiro do réu Francisco foram localizados em uma sacola na sua cintura. Relatou que o réu Caio confirmou que venderia os entorpecentes na festa de rodeio e o acusado Francisco permaneceu calado. Confirmou que os dois foram avistados juntos conversando e que os acusados disseram que não se conheciam.

Assim, ao término da instrução processual, é certa a prática do crime de tráfico pelos réus.

Quanto à validade dos depoimentos dos guardas, deve ser dado expressivo valor aos relatos apresentados pelas testemunhas ouvidas, pois não ficou demonstrado qualquer indício de sentimento pessoal de parte daqueles que efetivaram as prisões dos acusados em prejudicá-lo sem qualquer elemento concreto nesse sentido.

Esse é o entendimento jurisprudencial:

"TÓXICO - Tráfico - Insuficiência probatória - Inocorrência - Condenação fundada em testemunho de policiais - Validade - Depoimentos firmes e coerentes - Materialidade devidamente comprovada - Recurso não provido." (Apelação Criminal nº 229.463-3 - Guarujá - 2ª Câmara Criminal - 03.11.97. V. U.).

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Pretendida absolvição por insuficiência probatória - Inadmissibilidade - Solução condenatória lastreada exclusivamente na palavra de policiais - Inocorrência - Depoimentos válidos, encontrando amparo em outros elementos do processo - Relatos, ademais, que merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral - Recurso não provido. Como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando, sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale, não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial." (Apelação Criminal nº 189.074-3 - Palmital - 1ª Câmara Criminal - 02.10.95 - V. U.).

Assim "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos." (STF - HC nº 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

Ademais, Caio, em juízo, acabou por confessar a prática do crime, sendo que os guardas confirmaram ter encontrado em poder dele 94 pedras de crack e a quantia de R\$ 136,00 em notas trocadas. Os guardas disseram que o acusado acabou por confessar que estaria recebendo para fazer o transporte do entorpecente até um sítio. Desse modo, a confissão do Caio foi corroborada pela prova oral.

Francisco, por sua vez, negou a prática do crime, afirmando que em seu poder estava uma porção de maconha somente, além da quantia de R\$ 545,00.

Porém, a sua negativa restou isolada nos autos.

Com efeito, os guardas confirmaram que encontraram em poder do réu também a quantia de 31 papелotes de cocaína, dentro de sua roupa, não havendo qualquer motivo por parte dos agentes para incriminar o acusado. Desse modo, é certa também a propriedade dessa droga por parte do acusado Francisco.

Comprovada a propriedade da droga, resta analisar a sua finalidade e a outra conclusão não se chega senão a finalidade mercantil.

A forma de acondicionamento da droga, a sua quantidade e variedade, quantia em dinheiro apreendida sem comprovação de origem lícita, abordagem em local conhecido pela traficância, evidenciam que as substâncias entorpecentes se destinavam ao comércio ilícito, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

Ademais, as mensagens contidas em seu celular indicam a prática do comércio espúrio (fls. 130/188), afastando por total a alegação de que o acusado seria usuário de drogas.

Ainda que assim fosse, a mera alegação de que é usuário não tem o condão de permitir a desclassificação, conforme pretendido, pois como é sabido, normalmente encontram-se em uma mesma pessoa as figuras de usuário e traficante, sem que com isso saia ileso do crime de maior gravidade.

E todas as circunstâncias do caso em concreto, como já dito acima, comprovam a sua finalidade mercantil, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

Portanto, de rigor a condenação dos acusados pelo crime de tráfico de drogas.

Por outro lado, improcede a acusação quanto ao crime do artigo 35, caput, da Lei 11.343/06. Para a configuração do crime é necessário que se verifique que a associação é estável e permanente para o fim da prática dos ilícitos descritos no artigo 33 da referida lei.

No presente caso, a denúncia não demonstra que os acusados tinham uma mínima

associação entre eles. O simples fato de os acusados estarem juntos no momento da abordagem não é suficiente para o preenchimento dos requisitos da lei para que se reconheça o crime de associação. Ademais, a vontade de se associar deve ser distinta da vontade de praticar o crime visado para a configuração do delito. E havendo qualquer resquício de dúvida, de rigor a aplicação do princípio "in dubio pro reo", com a absolvição pelo delito tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Resolvido o mérito, passo à dosimetria da pena.

Com relação ao réu Francisco, na primeira fase da dosimetria da pena não verifico circunstâncias judiciais que justifiquem a elevação da pena acima do mínimo legal, motivo pelo qual fixo apenas em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa no valor unitário mínimo legal.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, verifico como recomendável seja aplicada a causa de diminuição contida no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, principalmente porque essa causa de diminuição da pena subsuma-se à situação do acusado em questão (primário e não se vê a existência de antecedentes efetivos para justificar o impedimento dessa benesse, sem, também, qualquer demonstração de que se dedica à atividade criminosa ou integre organização criminosa), motivo pelo qual ela faz jus à redução de 2/3. Assim, estabeleço a pena em 1 ano e 08 meses de reclusão, além de 166 dias-multa no valor unitário mínimo legal, tornando-a definitiva por não encontrar nenhuma outra circunstância modificadora aplicável.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, anteriormente, ao tratar de casos envolvendo o tráfico de entorpecentes, sempre entendi, em atenção ao disposto no art. 5º, XLIII, da CF, a integral aplicação dos rigores da Lei dos Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/90), a qual determina a imposição do regime inicial fechado (art. 2º, § 1º, com redação dada pela Lei nº 11.464/07), e da Lei nº 11.343/06, que veda a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, caput).

No entanto, ressalvada minha convicção pessoal, é necessário levar em consideração que, no âmbito dos Tribunais Superiores, em relação ao tráfico privilegiado, a Jurisprudência se consolidou para diferenciá-lo do tráfico em sua forma fundamental, tratando-o como delito não assemelhado a hediondo, sempre que preenchidos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Nessa ordem de ideias, o Plenário do E. STF, ao julgar o HC nº 118.533/MS, em 23/06/2016, decidiu que: "O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos". Em vista deste precedente, a 3ª Seção do C. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, por unanimidade acolheu a tese vitoriosa no STF, revisando o entendimento até então firmado com o enunciado nº 512 daquela Corte, atualmente cancelado (Pet nº 11.796/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe 29/11/2016).

Importante destacar, em tempo, as decisões do E. STF que em caráter incidental declararam inconstitucionais, por afrontarem a individualização da pena, tanto a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os crimes hediondos e equiparados (HC nº 111.840/ES, j. 27/06/2012), quanto a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos da Lei de Drogas (HC nº 97.256/RS, j. 01/09/2010), com a consequente promulgação da Resolução nº 5 de 2012 pelo Senado Federal, suspendendo a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Embora proferidas em processos individuais, sem eficácia vinculante, essas decisões da Corte Suprema devem ser observadas, em nome da segurança jurídica e na busca da uniformidade na resolução de conflitos.

Sob essas premissas, passo a analisar o caso dos autos, tendo como objetivo o apenamento proporcional às condições pessoais do infrator e das circunstâncias específicas do comércio ilícito por ele desenvolvido, afastada a hediondez do delito e suas consequências.

O presente caso, enfim, versa sobre a apreensão de 1 (uma) porção de maconha

pesando, no total, aproximadamente 2,0g (dois gramas), e 31 papelotes de cocaína, pesando no total, aproximadamente, 35g (trinta e cinco gramas), na posse de indivíduo primário, sem provas de conexão com as organizações criminosas ou traficância habitual.

Consequentemente, revendo posicionamento anterior e cedendo à orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores, fixo o regime inicial ABERTO para a execução da pena privativa de liberdade, nos moldes do art. 33, § 2º, "c", do CP. Ainda, porque presentes os requisitos correlatos, em atenção ao quantum de pena e à primariedade do réu, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, na forma do art. 44, § 2º, parte final, do CP.

A primeira consistirá na prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública, indicando o Juízo das Execuções tanto o destinatário como a espécie de serviço a ser prestado pelo tempo da pena substituída; a segunda em prestação pecuniária no valor de 02 salários mínimos na época do fato em favor de entidade pública ou privada, com destinação social, também a ser designada pelo Juízo das Execuções. Com relação ao acusado Caio, na primeira fase da dosimetria da pena não verifico circunstâncias judiciais que justifiquem a elevação da pena acima do mínimo legal, motivo pelo qual fixo a pena em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa no valor unitário mínimo legal.

Na segunda fase, verifico que o réu era menor de 21 anos na data dos fatos e, assim, reconheço a circunstância atenuante da menoridade relativa. Do mesmo modo, reconheço a atenuante da confissão, porém impossível a diminuição da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ), permanecendo a pena acima fixada.

Mudando entendimento anterior, ainda na terceira fase, não verifico como recomendável seja aplicada a causa de diminuição contida no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, o artigo em comento trata da figura do "traficante privilegiado", também chamada de "traficância menor" ou "traficância eventual, no qual estabelece a redução de pena de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa".

Quanto ao réu, apesar da primariedade técnica, impossível ignorar que o acusado está sendo processado pela mesma prática delitiva, tendo sido condenado em primeiro grau com a aplicação do referido benefício (autos 1501005-65-2021.8.26.0545 da 2ª Vara criminal desta Comarca), de modo que não se mostra cabível, portanto, a aplicação do referido benefício novamente.

Assim, torno definitiva para o acusado a pena de 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa no valor unitário mínimo legal, diante da ausência de causas modificadoras.

Pela quantidade da pena, não há que se falar em aplicação do artigo 44 ou 77 do Código Penal.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista que não se trata de tráfico privilegiado, equiparando-se ao crime hediondo, bem como a quantidade da pena aplicada, fixo o regime FECHADO para início de cumprimento de pena.

Isto posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal que o Ministério Público move contra FRANCISCO ALVES, para, com base no artigo 33, caput, c.c. parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, CONDENÁ-LO à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, bem como o pagamento de 166 dias-multa no valor unitário mínimo legal, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade nos termos acima deliberados; CONDENAR o acusado CAIO DUARTE à pena de 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa no valor unitário mínimo legal, em regime inicial fechado, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e ABSOLVÊ-LOS da imputação prevista no art. 35, "caput", da Lei nº 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Tendo em vista a natureza da pena, poderá o réu Francisco recorrer em liberdade.

Com relação ao réu Caio, verifico que os requisitos da prisão preventiva estão presentes, sobretudo a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, motivo pelo qual mantenho a prisão preventiva já decretada.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido por força desta sentença

e expeça-se guia de recolhimento provisória, caso haja recurso por qualquer das partes.

Comprovado que o dinheiro apreendido era produto do narcotráfico, decreto seu perdimento em favor da União (fls. 73).

Custas na forma da lei. Defiro a gratuidade processual. Anote-se.

Expeça-se o necessário.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Bragança Paulista, 30 de setembro de 2022.

Simone Rodrigues Valle
Juíza Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA